

114年公務人員特種考試司法官考試第二試
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試
法律專業科目評分要點與閱卷委員的話

科目：民法與民事訴訟法(一)

第一題

【總題說明】

本題分為三子題，分別涉及自由意思之形成是否為民法第184條第1項前段規定所保護之客體、表見代理之成立要件，以及抵押物第三取得人為清償是否為債之履行利害關係人，並得依民法第312條規定承受債權人之權利。

【評分要點】

第(一)子題

丙以被詐欺為由，依民法第184條第1項前段規定，請求甲賠償其所受之3,000萬元損害，有無理由？

本題，甲謊稱並出示不實證明文件使丙信A地已劃入市地重劃範圍，甲故意以積極不真之事實欺騙丙，致使丙陷於誤信，丙之自由意思形成過程中受到不當干涉，而為不利於己之意思表示，對丙構成詐欺。甲故意施行詐術，致丙表意自由受到侵害而受有3,000萬元損害，得否依民法第184條第1項前段規定請求損害賠償，涉及該項前段規定所保護之客體，討論如下：

1. 最高法院認為，民法第184條第1項前段規定所保護之權利，原則上限於既存法律體系所明認之權利，而不及於權利以外之利益。而純粹經濟上損失或純粹財產上損害，係指其經濟上之損失係為「純粹」者，而未與其他有體損害如人身損害或財產損害相結合而言；除係契約責任及同法第184條第1項後段及第2項規定所保護之客體外，並不涵攝在民法第184條第1項前段規定侵權責任所保護之範圍（參照最高法院110台上字第2150號判決、最高法院104年台上字第1577號判決）。
2. 至於表意人被詐欺而締結不利己之契約，其自由意思形成受侵害而有損害，是否為民法第184條第1項前段所保護之客體，學說存有不同見解：
 - (1) 甲說（否定說）：依此說之觀點，表意自由非民法第184條第1項前段規定所保護之客體，故不得依該條請求損害賠償。

本說見解為：民法第 184 條第 1 項前段所稱的「權利」，縱及於自由，但僅限於身體行動自由，而不及於精神活動自由，亦即不及於意思決定自由。因若過分擴大自由概念，將之及於意思決定自由，致使侵害他人自由成為概括條款，其保護範圍將難以確定，甚而影響個人行為自由及經濟活動。丙被甲詐欺，而與甲訂立不利益契約，丙被侵害之法益為表意自由，而表意自由非民法第 184 條第 1 項前段規定所保護之客體，丙不得依該條請求損害賠償。

至於甲之詐欺行為，符合故意以背於善良風俗之方法，加損害於丙時，丙得依民法第 184 條第 1 項後段規定請求賠償（參照最高法院 111 台上字第 176 號判決、最高法院 112 台上字第 1719 號判決）。另甲之行為若構成刑法第 339 條詐欺罪，丙得依民法第 184 條第 2 項規定請求損害賠償，屬另一問題。

- (2)乙說（肯定說）：依此說之觀點，丙被甲詐欺而訂立不利益契約，丙被侵害之法益為表意自由，表意自由為民法第 184 條第 1 項前段所保護之客體，丙依民法第 184 條第 1 項前段請求損害賠償，為有理由。

本說見解為：民法第 184 條第 1 項前段所定之權利概念，包括身體行動自由與精神活動自由，自亦及於表意自由或意思自主。民法第 184 條第 1 項前段所稱之「權利」及於表意自由，其理由在於：（a）表意自由與人格自主、人性尊嚴密不可分，屬人格法益之核心，具高位階法益價值，不宜以侵害表意自由概念有無限擴張可能性，而否定具權利屬性；（b）自由為基本權利或人格法益，內涵自包括身體行動自由與精神活動自由，不應刻意將其屬性區分為「權利」與「利益」以為差別對待；（c）表意自由或意思自主得以具體特定，客觀上亦得預見，不生保護範圍將難以確定之疑慮。丙因甲詐欺而訂立不利益契約者，丙被侵害之法益為表意自由，表意自由為民法第 184 條第 1 項前段規定所保護之客體，且甲之加害行為為故意，亦具不法性，加害行為與損害間有因果關係，丙得依民法第 184 條第 1 項前段請求損害。

第(二)子題

乙請求丁塗銷 B 地之抵押權設定登記，丁則抗辯甲出示乙之身分證、印章、B 地所有權狀、印鑑證明等文件，乙應負授權人責任，有無理由？

本題，乙就抵押權登記妨礙其對 B 地所有權之完整性，得否依民法第 767 條第 1 項中段規定向丁主張塗銷抵押權設定登記，取決於甲以乙名義所為之抵押權設定行為，是否構成表見代理而定，討論如下：

1. 民法第 169 條規定所稱之表見代理，係由自己之行為表示以代理權授與他人者，對於第三人應負授權人之責任，必須本人有表見之事實，足使第三人信該他人有代理權之情形存在，始足當之（最高法院 84 年度台上字第 2222 號判決意旨參照）。即是須本人有具體可徵之積極行為，足以表見其將代理權授與他人之事實，方足當之。倘無此事實，即不應令其對第三人負授權人之責任（參照最高法院 91 年度台上字第 1378 號判決）。甲持有並出示乙本人之身分證、印鑑章、印鑑證明、不動產所有權狀等不動產登記文件，客觀上足以讓丁信賴其有代理乙為 B 地設定抵押權行為之權限，構成權限外觀。甲趁乙出國，擅用乙交付之印章及身分證，盜取乙之 B 地所有權狀，偽造乙簽名申請印鑑證明，進而在土地登記申請書上偽造簽名以設定系爭抵押權等行為，能否謂乙有具體可徵之積極行為，足以使丁認甲代乙所為，有表見代理之情事，係屬可議。乙縱將身分證與印章一併交付於甲，但卻未交付 B 地所有權狀、授權書及申請印鑑證明等抵押權登記文件，抵押權之設定為甲盜取與偽造 B 地所有權狀、授權書及申請印鑑證明等文件所致，乙完全不知情。乙之行為不具備具體可徵積極行為，不足構成表見其將代理權授與甲之事實（參照最高法院 111 年度台上字第 222 判決）。
2. 學理認為表見代理成立要件有三，權限外觀之存在、第三人正當之信賴與本人之可歸責性。甲持有並出示乙本人之身分證、印鑑章、印鑑證明、不動產所有權狀等登記文件，足以使丁正當信賴乙有代理權之權限外觀，然乙無積極促成或容忍此權限外觀發生之可歸責行為，乙之行為不構成民法第 169 條規定之表見代理。

綜上，乙之行為欠缺具體可徵之積極行為或是無積極促成或容忍此權限外觀發生之可歸責行為，不構成民法第 169 條之表見代理，丁之抗辯無理由。乙未授權甲以乙之名義將其所有之 B 地設定抵押權於丁，作為甲向丁借款 1,500 萬元之擔保，甲擅以乙之名義為抵押權設定行為係無權代理，依民法第 170 條規定，乙得拒絕承認抵押權設定效力。B 地之抵押權登記，係侵害乙對 B 地所有權之完整性，乙依民法第 767 條第 1 項中段規定，請求丁塗銷 B 地抵押權登記，為有理由。

第(三)子題

乙屆期未清償其對戊之 1,000 萬元借款債務，庚恐 C 地遭拍賣，遂向戊清償該借款，經戊塗銷 C 地之抵押權登記後，庚請求乙給付 1,000 萬元，有無理由？

本題主要在評量考生對於民法第 311 條第 2 項、第 312 條規定債之履行有利害關係人之認定，以及利害關係人清償之效力。庚請求乙給付 1,000 萬元為有理由，討論如下：

1. 抵押權之追及效力

民法第 867 條規定，不動產所有人設定抵押權後，得將不動產讓與他人，但其抵押權不因此而受影響。乙將其所有 C 地設定抵押權於戊，以擔保其對戊借款 1,000 萬元後，乙將 C 地讓與於庚，戊對 C 地之抵押權不受影響，而乙不清償 1,000 萬元借款於戊，戊得對 C 地之受讓人庚實行抵押權。

2. 抵押權設定之後取得抵押物之人為債之履行之利害關係人

按債之清償，得由第三人為之；第三人之清償，債務人有異議時，債權人得拒絕其清償。但第三人就債之履行有利害關係者，債權人不得拒絕，此為民法第 311 條第 1 項本文、第 2 項分別定有明文。復按就債之履行有利害關係之第三人為清償者，得按其限度就債權人之權利，以自己之名義，代位行使，民法第 312 條前段定有明文。此有利害關係之第三人代位權，係以確保其求償權之實現為目的。而所謂就債之履行有利害關係第三人，如連帶債務人、不可分債務人、保證人、物上保證人、擔保物之第三人取得人或買受人、或承擔催收借款之借款中人等（最高法院 83 年度台上字第 2230 號判決意旨參照）。而所謂擔保財產之第三取得人，就抵押權而言，係指抵押物第三取得人，亦即抵押權設定之後取得抵押物之人（最高法院 65 年台上字第 796 號判例意旨參照）。庚向戊清償乙之借款 1,000 萬元，庚為抵押物第三取得人，係屬民法第 311 條第 2 項規定所稱之債之履行有利害關係第三人。

3. 債之履行有利害關係人之法定承受權

承前，依民法第 312 條規定，庚自得於清償 1,000 萬元限度內承受戊之權利，代位行使戊對乙之借款債權。按借用人應於約定期限內，返還與借用物種類、品質、數量相同之物，未定返還期限者，借用人得隨時返還，貸與人亦得

定一個月以上之相當期限，催告返還，民法第 478 條定有明文。乙之 1,000 萬元借款已屆清償期，庚得依第 312 條及第 478 條規定請求乙返還借款。

【閱卷委員的話】

第(一)子題

本子題多數應考人能指出表意自由確實係受民法相關制度保護，包括若意思表示形成過程中受不當干涉，例如重要而有影響之虛偽事實經積極表示為真，而使人陷於錯誤，或有告知義務但消極隱匿該事實，使他人既存之錯誤加深或保持，且該事實與表意人自由意思之形成有因果關係等情形，表意人自得依民法第 92 條規定行使撤銷權。

其次，多數應考人主要均能深入討論表意自由得否為民法第 184 條第 1 項前段規定保護之客體，雖有採否定說者，認民法第 184 條第 1 項前段所稱之「權利」縱及於自由，但僅限於身體行動自由，而不及於精神活動自由。惟詐欺行為若符合故意以背於善良風俗之方法，加損害於丙，丙得依民法第 184 條第 1 項後段規定請求賠償。另若採肯定民法第 184 條第 1 項前段規定之權利概念，包括身體行動自由和精神活動自由，即表意自由或意思自主者，與人格自主、人性尊嚴密不可分，為人格法益之核心，屬高位階之法益價值；即使從比較法例之絕對權觀點，人格權亦屬絕對權，故難謂應排除於民法第 184 條第 1 項前段所定「權利」。

有部分應考人將回答重點，放在意思表示之動機不應受保護，故不得依民法第 92 條撤銷意思表示或民法第 184 條第 1 項前段請求損害賠償，忽略甲對丙謊稱並出示不實證明文件之行為，並誤解丙以高於市價 4 倍之價格購買 A 地，與丙預期 A 地將上漲 4 倍之動機錯誤二者之差異，略屬缺憾。

第(二)子題

在本子題多數應考人能指出甲出示乙之身分證、印章、B 地所有權狀、印鑑證明等文件，涉及表見代理或是（狹義）無權代理，並引用我國實務見解須本人有具體可徵之積極行為，足以表見其將代理權授與他人之事實，方足當之（參照最高法院 91 年度台上字第 1378 號判決）。依題意乙縱將身分證與印章一併交付於甲，似構成權限外觀，但乙卻未交付 B 地所有權狀、授權書及申請印鑑證明等抵押權登記文件，抵押權之設定為甲盜取與偽造 B 地所有權狀、授權書及申請

印鑑證明等文件所致，乙完全不知情，乙之行為不具備具體可徵積極行為，不足構成表見其將代理權授與甲之事實(參照最高法院111年度台上字第222判決)，學理上亦認為乙無積極促成或容忍此權限外觀發生之可歸責行為，應不構成民法第169條之表見代理。

部分應考人以風險分配概念探討乙之行為是否具備具體可徵積極行為，並分析是否適用民法第169條規定，亦有見地。另有部分考生分析將回答重點放在行政機關之責任，以致回答離題稍遠。

第(三)子題

本子題之作答稍微不理想，本子題僅部分應考人能清楚指出民法第867條規定及抵押權之追及性，以及民法第311條與民法第312條相關第三人清償之規定。本子題庚向戊清償乙之借款1,000萬元，庚為抵押物第三取得人，係屬民法第311條第2項規定所稱之債之履行有利害關係第三人，且依民法第312條規定，庚自得於清償1,000萬元限度內承受戊之權利，代位行使戊對乙之借款債權。

部分應考人兼述庚得另依無因管理或不當得利請求，自無不可。但若僅討論此而完全未討論抵押權追及性與第三人清償，則稍嫌可惜。值得一提者，另有應考人指出庚所有之C地雖設定擔保1,000萬元債權之抵押權，但庚未承擔C地該1,000萬元債務清償責任，推測乙庚間債權契約已有價金上之減少，雖不符題意，但能有此問題意識，仍值得肯定。

第二題

【總題說明】

本題分為三子題，分別涉及生父認領非婚生子女之要件與效力，包含出養與親權之行使、姻親關係之消滅與近親收養禁止之規定，以及喪失繼承權事由中以無效遺囑為表示失權之效力與法定應繼分之計算。

【評分要點】

第(一)子題

丁與庚生有非婚生子女辛，而由丁單獨與丙、戊夫妻訂立出養辛之收養契約

效力為何？又庚得否向法院請求酌定對辛之權利義務行使與負擔？

本題丙、戊欲收養辛，而單獨與丁訂立收養契約，該收養之契約有效與否，視其收養之形式與實質要件是否合法，包括應由其法定代理人代為並代受意思表示(1076-2)，夫妻應共同收養(1074)、不違反近親收養(1073-1)以及應經本生父母同意(1076-1)等要件，否則法院應不予認可，而使收養不生效力(1079II)。丙、戊為夫妻共同收養辛，並與辛為旁系血親三親等以內但輩分相當，並不違反近親收養禁止與夫妻共同收養之規定。猶有疑問在於丁得否單獨以法定代理人之身分單獨與丙、戊訂立收養契約而發生效力，涉及辛之生父庚是否有認領辛。丁與庚雖於辛 1 歲後即分手，然庚自丁懷胎後即細心照料丁，更與丁約定辛應從庚姓，足見庚以辛之生父自居，並定期給付生活費而具備撫育之事實行為，故庚對辛已為認領。認領之效力溯及於辛出生時，而視為庚之婚生子女（第 1069 條規定參照），因而無論庚是否取得辛之法定代理人之身分，該收養契約均應經本生父母之同意，從而欠缺庚之同意下，該收養契約無效。

至於庚得否向法院請求酌定對辛之權利義務行使與負擔，依民法第 1069 條之 1 規定，非婚生子女經認領者，關於未成年子女權利義務之行使或負擔，準用第 1055 條、第 1055 條之 1 規定。庚既已認領辛，自為辛之法定父親，得對其未成年子女行使親權，然庚因與辛之生母丁分手，兩人不再共同生活，故得準用離婚後親權酌定之規定，於對辛之親權如何行使未為協議或協議不成者，向法院請求酌定欲單獨對辛行使親權，而由法院依子女最佳利益判斷之。

第(二)子題

甲、乙夫妻在其子丙去世後，與丙之妻戊訂立收養契約。向法院提出收養之聲請，法院得否為收養認可之裁定？若甲乙與戊事先訂立書面之姻親關係終止之契約，結果是否不同？

本題涉及收養之實質要件，即直系姻親不得收養為養子女（第 1073-1 規定參照）。該條規定意旨係為維護我國傳統倫理觀念，不使夫妻因收養而為兄弟姊妹。惟若夫妻一方去世，他方父母可否收養夫妻之他方，於姻親關係未為終止之情形下，不無疑義。由於姻親關係僅因離婚或婚姻經撤銷而消滅，不及於夫妻一方死亡之情形（971），故丙死亡之後，甲、乙與戊之直系姻親關係仍未消滅，而違反上述收養之實質要件，法院應不予認可（1079II, 1079-4）。

至於甲、乙得否與戊事先訂立書面之終止姻親關係契約，據以向法院聲請認可收養，尚有不同之見解。由於身分關係具有公益性，不得由當事人自行處分，故基於血緣或婚姻所建立之血親或姻親之身分關係，在法無明文之情形下，應無任由當事人以契約解消之可能，否則該契約亦有違反公序良俗與強制或禁止規定之疑慮。惟實務上有裁判認為在配偶一方死亡使婚姻解消之情形下，未有當事人基於自主意思而合意解消非基於血緣而生之姻親關係，屬剝奪生存配偶及死亡配偶血親之人格自由，而形成法律漏洞。此時得類推養父母子女合意終止收養契約之規定，以填補該法律漏洞。在本案例事實中，如依上開實務見解，丙之父母甲、乙與丙之妻戊，自得於丙死亡之後，以書面合意終止彼此之姻親關係，無須再經法院之認可，其姻親關係於書面之契約成立時起即發生解消之效力。此時，甲、乙與戊自得以雙方合意訂立之書面收養契約向法院聲請收養之認可，法院在未有違反近親收養禁止之規定下，並依成年收養認可之標準，於該收養未對本生父母有不利之情形下，認可該收養（第 1079 條之 2）。惟若認身分關係具有公益性，有人倫輩分之考量，應不得由當事人自由處分而以契約解消姻親關係，則該終止姻親關係之書面契約應為無效，彼此仍屬於禁止收養之親屬，法院自得因民法第 1079 條第 2 項規定，因收養有無效原因（第 1079 條之 4），而不予收養之認可。

第(三)子題

甲死亡後留下遺產新臺幣 1,500 萬元，應如何繼承？

本題涉及甲之法定繼承人為何人與遺產應如何分配。有關甲之法定繼承人為其配偶以及直系血親卑親屬。甲死亡後，其繼承人為其配偶乙，其子丙因先於甲死亡，不符合同時存在原則不為繼承人，其媳婦戊與甲為姻親關係，亦非繼承人。

丁為甲之女，雖為第一順序之血親繼承人，然其對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者，喪失繼承權（1145 I, 5）。依該條規定之要件，除有重大之虐待或侮辱情事，即對被繼承人以身體上或精神上痛苦之行為，並須依社會觀念衡量之外，更須有被繼承人之表示，惟該表示行為之方式，法無明文，屬不要式行為，亦無庸向特定人為之，但若以遺囑表示失權時，有認為應解釋為仍須依遺囑之方式為之；但亦有不同見解，即為不要式行為，只要被繼承人一旦為表示後，繼承人即喪失繼承權，因此經被繼承人以剝奪繼承權

之意思載明於一文書上時，即生失權之效果，不論該文書是否為遺囑，亦不應以該遺囑欠缺法定方式而認定該行為無效。在本案例事實中，丁曾對甲以言詞辱罵，多年沒有來往，至甲死亡前亦未為探望，足以致甲感受精神上莫大痛苦，已構成重大之虐待行為（最高法院 74 年台上字第 1870 號判決參照）。惟甲以代筆遺囑之方式，剝奪丁之繼承權，該表示行為是否因遺囑有效成立而連帶影響其效力，涉及學說不同見解：第一說視其代筆遺囑之有效與否定之，由於代筆遺囑欠缺見證人之簽名而無效，故甲之表示行為亦無效，丁不喪失繼承權；第二說則認為表示行為不以要式為必要，一經表示即生失權之效果，縱以遺囑方式為之，其欠缺法定要件者亦然。如是，丁即喪失繼承權，並依民法第 1140 條規定，由其子辛代位繼承。

配偶與第一順序之血親繼承人共同繼承時，應繼分應與他繼承人平均（第 1144 規定參照）。代位繼承人繼承時，繼承被代位人之應繼分（第 1140 規定參照）。因此，如採第一說者，甲所留下遺產 1,500 萬元應由配偶乙與女兒丁共同平均繼承，各得 750 萬元。採第二說者，甲留下遺產 1,500 萬元應由配偶乙，以及代位繼承人辛共同平均繼承，各得 750 萬元。

【閱卷委員的話】

本題身分法涉及非婚生子女的認領、收養、親權酌定，成年收養與終止姻親關係，以及表示失權之繼承問題。整體而言，多數考生尚能掌握重點答題，茲分別說明如下。

第(一)子題

本子題之主要爭點，在於丁女將其與庚男同居懷孕所生之未滿 7 歲之辛，單獨出養於其兄丙與嫂嫂戊，是否違反民法第 1073 條之 1 第 3 款關於禁止收養近親規定之記載，並抵觸民法第 1076 條之 2 第 1 項應得辛之法定代理人同意之規定？經查辛與丙戊間為旁系血親三親等且輩分相當，尚無抵觸禁止收養之規定；又考量生父庚定期給予生活費、細心照料丁及其腹中胎兒之撫育事實，應認庚對辛已為認領，辛之法定代理人為丁庚二人。今丁將辛單獨出養，因未得庚之同意，依民法第 1079 條之 4 規定，洵屬無效。就此部分，多數考生殆有提及。

至於庚因與辛之生母丁分手，兩人不再共同生活，故庚得依民法第 1069 條之 1 規定，準用離婚後親權酌定記載，向法院請求酌定對辛之權利義務的行使

與負擔。這部分完全答對者較少，分數因生差距。

第(二)子題

首先，大多數考生有提及依民法第 971 條規定，姻親關係僅因離婚或婚姻經撤銷而消滅，不包括夫妻一方死亡之情形。本題丙死後，甲乙與其媳婦戊，仍為直系姻親，雙方訂立書面之收養契約，因違反民法第 1073 條之 1 第 2 款規定，洵屬無效，法院應不予收養認可。

其次，約半數考生論及姻親關係是否得以書面合意終止的實務爭議，可資稱許。時實務上，最高法院 112 年度台簡抗字第 79 號民事裁定認為，民法由姻親關係所發生之權利義務，較收養關係為輕微，基於保障人格自由實現及發展之同一法律理由，應依平等原則，將民法第 1080 條第 1 項、第 2 項關於合意終止收養規定，類推及於未經法律規範之合意終止姻親關係，以填補該法律漏洞。又該終止行為，非必須由法院介入，亦有最高法院 112 年度台簡抗字第 106 號民事裁定在案可稽。準此，丙死後，其父母甲乙與媳婦戊女，得類推適用民法 1080 條第 1 項與第 2 項規定，以書面合意終止姻親關係，毋須向法院聲請終止姻親關係。果爾，如甲乙與戊事先訂立書面之終止姻親關係契約，因不復存在禁止收養直系姻親之情形，法院得准予收養之認可，其結果自有不同。

另有考生以身分關係具有公益性，不得由當事人自行處分為由，認為甲乙與戊訂立書面之終止姻親關係契約，殆屬違反公序良俗而無效，亦有相當理由。此外，少數考生提到承認合意終止姻親關係，應以法律明文規定，俾臻明確，且有戶籍法上登記之行政管理的配套措施，較為妥適。否則縱令甲乙與戊得以書面契約合意終止姻親關係，該姻親終止之效力是否及於當事人（甲、乙、戊）以外之第三人（丁、辛）？易滋疑義。如辛男長大後與戊女結婚，是否牴觸民法第 983 第 1 項第 3 款關於旁系姻親在五親等以內、輩份不相同者，不得結婚之規定？令人頗費思量。渠等質疑實務看法之意見，亦有見地。

第(三)子題

本子題的主要爭點，在於被繼承人甲以無效遺囑為民法第 1145 條第 1 項第 5 款所定表示失權之效力。本題丁以言語辱罵甲之後，多年沒有來往，至甲重病入院始終未為探望，依我國實務見解，足以致甲感受精神上莫大痛苦，已構成重大之虐待行為。惟甲在欠缺見證人簽名而無效之代筆遺囑中，表明不讓丁繼承其

財產，是否會使原本不要式之表示失權，因遺囑無效而失其效力？多數考生以尊重被繼承人之意思為由，採取否定看法，從而丁喪失繼承權，由辛代位繼承之，乙、辛各分得 750 萬元。部分考生則以喪失繼承權較諸遺囑無效嚴重許多，若連表示失權之載體、代筆遺囑都因欠缺法定要式罹於無效，則涉及剝奪丁繼承權之表示情事更應嚴格認定，允宜以符合遺囑要式之方式為之，較為嚴謹妥適。倘若如是，甲之表示失權因遺囑無效亦失其效力，故丁不喪失繼承權，乙、丁各分得 750 萬元。兩說論據，均有一定之說服力。